

1501123-41.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Marzola Colombini

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... da ré pela prática do crime de tráfico de drogas, afastando-se, no entanto, a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas (cometimento do crime em transporte público) e, também, da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal (tráfico privilegiado).

A Defesa, por sua vez, em memoriais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

3ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501123-41.2021.8.26.0545 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501123-41.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282493/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 20857738 -

DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2282493 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gismara de Lima Ferreira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Marzola Colombini

VISTOS.

GISMARA DE LIMA FERREIRA foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, incisos III e V, ambos da Lei nº 11.343/06, e está sendo processada porque, no dia 15 de outubro de 2021, no horário e no endereço mencionados na denúncia, em transporte público e visando à transposição de fronteiras entre Estados da Federação, teria trazido consigo e transportado drogas, consistentes em 01 tijolo de crack (pesando, aproximadamente, 520,2 gramas - peso bruto) e 01 tijolo de skank (pesando, aproximadamente, 985 gramas - peso bruto), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

A ré foi notificada (fls. 136) e apresentou defesa preliminar às fls. 142/145.

A denúncia foi recebida às fls. 146/148.

Citada (fls. 173), em audiência de instrução e julgamento (fls. 181), foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação em comum com a Defesa, sendo, ao final, realizado o interrogatório da acusada, conforme gravação audiovisual constante dos autos.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em debates orais, se manifestou requerendo a procedência do pedido acusatório, com a consequente condenação da ré pela prática do crime de tráfico de drogas, afastando-se, no entanto, a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas (cometimento do crime em transporte público) e, também, da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal (tráfico privilegiado).

A Defesa, por sua vez, em memoriais escritos de fls. 199/203, requereu que, na hipótese de condenação da acusada pela prática do crime de tráfico de drogas, fosse a pena fixada no mínimo legal, com o reconhecimento, ainda, da atenuante genérica da confissão espontânea. Por fim, postulou a concessão da prisão domiciliar em favor da ré.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

No mérito, de rigor a parcial procedência do pedido acusatório, para o fim de condenar a ré pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo-se a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, incisos V, da Lei de Drogas (tráfico entre Estados da Federação), e afastando-se, por outro lado, tanto a causa especial de aumento de pena prevista no inciso III, do mesmo dispositivo legal (crime cometido em transporte público), quanto a causa especial de diminuição de pena insculpida no artigo 33, § 4º, da lei em questão.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada pelas fotografias de fls. 22/24, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 25/26, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 27, pelo boletim de ocorrência de fls. 28/32, pelos laudos periciais de exame químico toxicológico de fls. 85/87 e 89/91, bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, da mesma forma, é inequívoca.

A ré Gismara de Lima Ferreira, na fase policial (05), se manteve em silêncio.

Em juízo, confessou a prática delitiva, aduzindo que: possui 27 anos de idade; antes de ser presa, trabalhava recolhendo recicláveis; reside na cidade de Itajubá/MG; possui passagem por tráfico de drogas no Estado de Mato Grosso do Sul (transporte de maconha - processo ainda em trâmite); no Estado de Minas Gerais, foi condenada por porte de drogas para consumo pessoal; possui dois filhos (uma filha de 4 anos de idade e um filho de 2 anos), que estão sob os cuidados de sua genitora, na cidade de Itajubá/MG; a acusação é verdadeira; realmente estava transportando as drogas descritas na denúncia por ocasião de sua abordagem pelos policiais rodoviários federais; estava transportando as drogas para a cidade de Itajubá/MG; iria ganhar a quantia de mil reais pelo transporte dos entorpecentes; foi a primeira vez que transportou drogas no Estado de São Paulo (já tinha transportado drogas, anteriormente, no Estado de Mato Grosso do Sul); cometeu o

crime porque estava desempregada e necessitando de dinheiro para ajudar sua genitora; está arrependida da prática do delito; embora fizesse uso de maconha, não é viciada em entorpecentes.

Tal confissão merece ser considerada pelo Juízo, posto que se encontra em consonância com as demais provas carreadas aos autos.

Isto porque o Policial Rodoviário Federal Helton de Paula Pena, em juízo, narrou que: por ocasião dos fatos, estavam realizando fiscalização a ônibus em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, na cidade de Atibaia, quando procederam à abordagem a um ônibus da Viação Santa Cruz, que havia saído da cidade de São Paulo e seguia em direção à cidade de Itajubá/MG; ao ingressarem no ônibus, passaram a entrevistar a acusada, que esboçou nervosismo após ser questionada acerca da existência de eventuais passagens criminais; a acusada informou que tinha passagem criminal no Estado do Mato Grosso do Sul por transporte de grande quantidade de entorpecente; solicitaram à ré que abrisse a mochila que ela trazia nas mãos; com a abertura da mochila, sentiram forte odor característico de maconha; em revista à referida mochila, encontraram duas sacolas, sendo que em uma delas constava um tablete de crack (que pesava cerca de 499 gramas) e, na outra, constava um tablete de Skank (que pesava cerca de 963 gramas); a réu informou que estava transportando os entorpecentes para a cidade de Itajubá/MG e que receberia a quantia de mil reais pelo transporte; a acusada alegou, ainda, que não poderia fornecer mais detalhes acerca do local em que havia pegado o entorpecente e para quem o entregaria; em seguida, a acusada foi conduzida à delegacia de polícia da cidade de Atibaia; não foi constatada a participação de outra pessoa no cometimento do delito; não conhecia a acusada anteriormente; a acusada não alegou qualquer motivo particular para cometimento do crime; reconhece a acusada como sendo a mesma pessoa abordada por ocasião dos fatos.

Por fim, corroborando tal relato, o Policial Rodoviário Federal Caio César Dias Fernandes, em juízo, asseverou que: na data dos fatos, estavam realizando operação de fiscalização a ônibus quando, defronte à base da Polícia Rodoviária Federal, realizaram a abordagem de ônibus que seguia em direção ao Estado de Minas Gerais; em revista ao interior do ônibus, seu colega de farda percebeu que a ré apresentou grande nervosismo ao ser abordada; seu colega de farda encontrou dois tabletas de entorpecente em poder da acusada; a acusada confessou que estava transportando as drogas para uma cidade do Estado de Minas Gerais; não conhecia a ré anteriormente aos fatos; a acusada alegou que recebia a quantia de mil reais por cada viagem que realizava transportando entorpecente.

Nesse contexto, dúvidas não restam acerca da caracterização do crime de tráfico de drogas, pelos seguintes motivos: i - elevada quantidade e variedade de entorpecente apreendido (um tijolo de crack, pesando cerca de 520,2 gramas - massa bruta; e um tijolo de Skank, pesando cerca de 985 gramas - massa bruta); ii - confissão integral da acusada, em juízo, no sentido de que se encontrava transportando os entorpecentes da cidade de São Paulo/SP para Itajubá/MG; iii - confissão informal da acusada aos agentes policiais, por ocasião da abordagem; e iv - depoimento dos policiais rodoviários federais Helton e Caio, que confirmaram a apreensão do entorpecente no interior de um ônibus que seguia para a cidade de Itajubá/MG, bem como a confissão informal da acusada quanto à posse dos entorpecentes.

Destaco que a confissão judicial da acusada restou em plena harmonia com o depoimento dos policiais rodoviários federais Helton e Caio, razão pela qual, nos termos do art. 197, do Código de Processo Penal, merece ser considerada como meio de prova.

Ademais, insta ressaltar que não há que se falar em ausência de credibilidade no relato dos policiais, na medida em que, na condição de testemunhas, suas palavras ostentam o mesmo valor probatório que o de qualquer outra, não se podendo retirar a

boa-fé pelo só fato de serem agentes de segurança. Nesse sentido:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar, tal como ocorreu com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 74.608-0-SP, rel. Min. Celso de Mello).

Na verdade, o testemunho de policiais merece fé até prova em contrário (RT 426/439), desde que não fique demonstrada a sua inidoneidade (RT 444/406), ou o seu propósito deliberado de incriminar falsamente o réu (RT 454/422), o que não se verificou na hipótese dos autos, até mesmo porque os agentes policiais sequer conheciam a acusada anteriormente aos fatos.

No mais, destaco que houve a devida caracterização da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, em virtude de o tráfico ter se caracterizado entre estados da Federação (São Paulo e Minas Gerais).

Nessa esteira, levo em consideração a própria confissão da ré – no sentido de que receberia a quantia de mil reais para transportar os entorpecentes da cidade de São Paulo até a cidade de Itajubá, situada no estado de Minas Gerais –, corroborada pelos depoimentos harmônicos dos agentes policiais (relataram que, informalmente, a acusada confessou que receberia a quantia de mil reais para transportar as drogas até uma cidade do estado de Minas Gerais).

Outrossim, o documento de fls. 21 (Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico), emitido em nome da ré, também comprova que o ônibus no qual ela se encontrava tinha como destino a cidade de Itajubá/MG.

Devidamente configurada a causa de aumento em análise, suficiente se mostra, no entanto, a fração mínima de 1/6 para o aumento de pena, diante do envolvimento de apenas dois Estados da Federação (São Paulo e Minas Gerais).

Nesse âmbito:

“A gradação – de um sexto a dois terços – deve cingir-se ao grau de interestadualidade do crime: quanto maior o número de Estados-membros abrangidos pela atividade do agente, maior deve ser o aumento. Se envolver apenas dois Estados-membros, por exemplo, o aumento de um sexto é suficiente.” (NUCCI, Guilherme de Souza; Leis Penais e Processuais Penais comentadas – vol. 1 – 10 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 432/433).

Destaco, no mais, que o fato de não ter ocorrido a devida transposição da droga para o Estado destinatário (Minas Gerais) em nada prejudica a caracterização da causa de aumento de pena em questão.

Nesse sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima (“Legislação Criminal Especial Comentada”: volume único – 5. Ed. Rev. Atual. e Ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2017, p. 1.065):

“[...] é dominante o entendimento no sentido de que não é necessária a efetiva transposição da divisa interestadual. Na verdade, basta a presença de evidências de que a substância entorpecente tinha como destino qualquer ponto além das linhas divisórias estaduais.”.

Também é o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal:

"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser desnecessária a efetiva transposição das fronteiras interestaduais para a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, 'bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação' (HC 115.893, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje de 04.06.2013". (RHC 122.598, 2ª T., rel. Teori Zavascki, j. 14.10.2014, Dje-214, Divulg. 30.10.2014, Public. 31.10.2014)

Saliento, ainda, que tal questão restou pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 587, que assim estabelece:

"Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual."

Assim sendo, ainda que a ré sequer tenha deixado o estado de São Paulo, o delito restou caracterizado, sendo desnecessária a efetiva transposição para o Estado de Minas Gerais.

Em se tratando de tráfico interno (e não internacional), ainda que entre estados da Federação, dúvidas não há acerca da competência da Justiça Estadual.

No tocante à causa de aumento estabelecida pelo art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, entendo, por outro lado, que não houve a devida configuração.

Isto porque, consoante a jurisprudência tanto do C. Superior Tribunal de Justiça quanto do C. Supremo Tribunal Federal, para que a majorante em questão se caracterize não basta que o agente tenha se utilizado de transporte público para a circulação da substância entorpecente.

Com efeito, entendem os referidos Tribunais Superiores que se faz necessária a efetiva comercialização do entorpecente no interior do transporte público, ou a intenção de comercializá-lo em seu interior, para que haja a incidência da majorante em tela.

A par disso, verifico que, in casu, as provas carreadas aos autos não evidenciaram que a ré estivesse comercializando os entorpecentes no interior do ônibus ou que, pelo mesmo, pretendesse comercializá-lo no interior do transporte público,

Ao contrário, as provas foram firmes no sentido de que a acusada se utilizou do transporte público apenas para conduzir as drogas até a cidade onde deveria entregá-las para o suposto contratante do "serviço".

Sendo assim, o afastamento da causa de aumento em questão é medida imperativa.

No sentido do exposto:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de que o simples fato de o agente utilizar-se de transporte público para conduzir a droga não atrai a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, que deve ser aplicada apenas quando constatada a efetiva intenção de comercialização da substância em seu interior. Ressalva de entendimento. 2. No caso em exame, a droga estava escondida no interior de um bote inflável levado no bagageiro do ônibus, motivo pelo qual não incide referida

majorante. 3. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no REsp: 1379010 MS 2013/0128072-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019)

No mais, verifico também ser a hipótese de não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em virtude do nítido envolvimento da acusada em atividade criminosa, que restou evidenciado em razão da apreensão de enorme quantidade e variedade de drogas (um tijolo de crack, pesando, aproximadamente, 520,2 gramas - massa bruta; e um tijolo de Skank, pesando, aproximadamente, 985 gramas - massa bruta). Outrossim, a acusada confessou, em juízo, que receberia a quantia de mil reais pelo transporte dos entorpecentes.

Ainda neste particular, consigno que o entendimento da jurisprudência é firme no sentido de a quantidade e variedade de entorpecentes poderem ser utilizadas, dentre outros elementos, como indicativos de envolvimento do agente em atividade criminosa, afastando, por conseguinte, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena em questão.

A propósito, transcrevo ementas de julgados proferidos pelo C. Supremo Tribunal Federal, sempre no sentido de se afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado nas situações acima mencionadas, ante a constatação de dedicação do réu às atividades criminosas:

"Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicção à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Improriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. 1. A negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 pelas instâncias ordinárias não está lastreada em presunções, ilações ou conjecturas. Pelo contrário, apresentaram elas elementos concretos que apontam não só que o paciente atuou conscientemente a rogo de organização criminosa, como também se dedicava à atividade ilícita, ficando demonstrado que ele teria realizado outras viagens em circunstâncias indicativas de transporte de drogas. 2. Tal qual se deu na espécie, "a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa" (HC nº 119.053/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/14). 3. A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes". (STF, HC 141292/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Julgado 15/04/2017, Publicado em 22/05/2017)

"Na hipótese, destacou o Tribunal de origem que a quantidade de droga apreendida (3 quilos de cocaína) evidencia o seu grau de envolvimento com o tráfico de drogas, distinguindo-o, portanto, do traficante ocasional. Para efeitos de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006: a conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas". (STF, RHC 94.806/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe 16/04/2010)

Ainda no mesmo sentido, ensina Renato Brasileiro de Lima ("Legislação Criminal

Especial Comentada", 2ª edição, Editora Jus Podivm, 2014, p. 743/744) que: "Da mesma forma, se o indivíduo for flagrado com grande quantidade e variedade de drogas, tem-se aí forte indicativo de que se trata de agente dedicado a atividades criminosas, até mesmo porque não é normal que um traficante pequeno e eventual dê início às atividades de traficância com tamanha quantidade e diversidade de drogas".

Com se não bastasse, sublinho que a ré responde, atualmente, a outro processo criminal, no estado do Mato Grosso do Sul, devido à acusação de prática de delito idêntico ao que se encontra em julgamento (tráfico interestadual de drogas), cf. informado pela própria acusada no interrogatório judicial e corroborado pela certidão de fls. 197/198 (Autos nº 0001799-16.2020.8.12.0002, da 2ª Vara Criminal de Ponta Porã – delito cometido em 22/04/2020), circunstância esta que também pode ser utilizada pelo Julgador como indicativo de que o agente se dedica a atividades criminais.

Nesse aspecto, insta sublinhar que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A propósito:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça.” (EResp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017)

Por fim, rejeito a tese de autodefesa de estado de necessidade – em razão da alegação da ré de que cometeu o delito porque se encontrava em dificuldades financeiras e em situação de desemprego.

Acerca do assunto, ensina Cleber Masson (“Código Penal Comentado”, Editora Método, 3ª edição, 2015, p. 195/196), ao comentar a distinção entre a referida excludente (estado de necessidade) e as dificuldades econômicas, que: “Não se confundem. No estado de necessidade, o agente é compelido a praticar o fato típico, para afastar a situação de perigo atual ou iminente, involuntário e inevitável, capaz de afetar bem jurídico próprio ou de terceiro, cujo sacrifício é inexigível. Na dificuldade econômica supõe-se que o indivíduo deva conformar-se com a privação, porque não se cuida do suprimento de necessidade vital ou primária, ou, ainda que disso se trate, que lhe seja possível satisfazer a carência por meio de atividade lícita. Em qualquer das hipóteses não se justifica a lesão ao interesse de outrem. Destarte, a

dificuldade econômica, inclusive com a miserabilidade do agente, não constitui estado de necessidade. Em casos excepcionais, admite-se a prática de um fato típico como medida inevitável, ou seja, para satisfação de necessidade estritamente vital que a pessoa, nada obstante seu empenho, não conseguiu superar de forma lícita, a exemplo do furto famélico, em que o sujeito subtrai alimentos básicos para saciar a sua fome ou de pessoa a ele ligada por laços de parentesco ou de amizade. Portanto, se o agente podia laborar honestamente, ou então quando se apodera de bens supérfluos ou em quantidade exagerada, afasta-se a justificativa”.

No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça também decidiu que:

“Estado de necessidade – dificuldades financeiras – não caracterização: a afetação da qualidade de vida, mesmo implicando em dificuldades financeiras, por si só, não preenche os requisitos do status necessitatis (art. 24 do CP)” (REsp 499.442/PE, rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 24.06.2003)

Ademais, imperioso destacar que a ré não comprovou a existência de dificuldade econômica e de perigo atual que justificassem o sacrifício de bem alheio, ônus da prova que, a toda evidência, lhe competia (art. 156, do Código de Processo Penal).

Em outras palavras, a conduta da acusada não se amoldou às condições necessárias ao reconhecimento do estado de necessidade, razão pela qual se revela impossível o seu reconhecimento no caso concreto.

Destarte, diante das provas carreadas aos autos, impõe-se a condenação da acusada pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei de Drogas, e afastando-se, por outro lado, tanto a causa de aumento prevista no inc. III, do referido dispositivo legal, quanto a causa especial de diminuição de pena concernente ao tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33, da Lei de Drogas).

Verificadas, assim, materialidade e autoria delitivas do crime descrito na inicial acusatória, passo, pois, à fixação da pena a ser imposta à acusada.

Na dosagem da pena-base, nos termos do artigo 42, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que a elevada quantidade e variedade de entorpecente apreendido (um tijolo de crack, pesando, aproximadamente, 520,2 gramas – massa bruta; e um tijolo de skank, pesando, aproximadamente, 985 gramas – massa bruta) já foi utilizada para o afastamento da figura do tráfico privilegiado (redutor da 3ª fase), fixo a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, verifico a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. No entanto, a pena já foi fixada no mínimo legal (Súmula 231, do C. Superior Tribunal de Justiça). Consigno que a acusada é tecnicamente primária, cf. Pesquisa SIVEC de fls. 34/35, Certidão de Distribuição Criminal de fls. 36 (estado de São Paulo), Relatório de Registros Policiais/Judiciais de fls. 122/128 (estado de Minas Gerais), Folha de Antecedentes Criminais de fls. 130 (estado do Mato Grosso do Sul), Certidão Criminal de fls. 178/180 (estado de Minas Gerais) e Certidão de Antecedentes Criminais de fls. 197/198 (estado do Mato Grosso do Sul).

Finalmente, na terceira fase, em virtude da incidência da causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, aumento a pena em mais 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Ainda, imperioso destacar que a acusada não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pelos motivos supramencionados.

Torno definitiva a pena acima.

O dia-multa será fixado em seu mínimo legal, ante a ausência de informações específicas acerca da situação financeira da acusada, salvo aquela fornecida por ocasião de seu interrogatório judicial, insuficiente para tal finalidade.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo o fechado, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta da acusada (tráfico entre estados da federação, elevada quantidade de entorpecente, diversidade de espécies, prisão em flagrante da ré na prática do tráfico em outros estados da federação, etc), na forma do art. 33, § 3º, do Código Penal, não desconhecendo este Juízo, todavia, a recente tese de Repercussão Geral fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 1052700, de relatoria do Exmo. Ministro Edson Fachin, no sentido da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos. Ademais, a fixação de regime inicial mais brando não alcançaria, de forma expressiva, os objetivos de repressão e prevenção visados pelo Direito Penal.

Entendo não ser cabível, outrossim, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, tendo em vista a quantidade de pena aplicada (superior a 04 anos), além do fato de tal medida não se mostrar adequada e suficiente no caso concreto (requisitos subjetivos) – art. 44, inc. III, do Código Penal.

A ré não poderá apelar em liberdade, uma vez presentes os requisitos que culminaram com a decretação de sua prisão preventiva. A detração, para fins de eventual progressão (a acusada se encontra presa preventivamente há pouco mais de três meses), deverá ser melhor analisada pelo Juízo das execuções, inclusive em sede de execução provisória, não vislumbrando o Juízo da condenação motivo plausível e evidente para alteração do regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Outrossim, em que pese o pleito formulado pela Defesa em sede de memoriais escritos, entendo que a acusada não faz jus ao benefício da prisão domiciliar.

Com efeito, o art. 318, do Código de Processo Penal, estabelece ao juízo a faculdade de conceder prisão domiciliar quando o agente for “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (cf. inc. V, do referido dispositivo).

Pois bem. Em que pese este Juízo ter juntado aos autos, a pedido da Defesa, documentos que comprovam o fato de a ré ser genitora de dois filhos menores de 12 anos de idade (fls. 189: certidão de nascimento da filha Maria Alice, que, atualmente, conta com 4 anos de idade; fls. 190: certidão de nascimento do filho Anthony Emanuel, que, atualmente, conta com 2 anos de idade), entendo inviável, no caso concreto, a concessão da prisão domiciliar.

Isto porque há elementos nos autos que autorizam concluir que as crianças estão sendo bem cuidadas por familiares, que lhes garantem o bem-estar e um saudável desenvolvimento. Nesse viés, consigno que a própria acusada, no início do seu interrogatório judicial, afirmou que os filhos estão sendo cuidados por sua genitora (avó das crianças), que reside na cidade de Itajubá/MG.

Além disso, cabe salientar a gravidade das circunstâncias envolvendo os fatos em questão – mormente o fato de já ser a segunda vez, em menos de dois anos, que a acusada é flagrada realizando transporte interestadual de drogas -, a qual inequivelmente, autoriza a manutenção da prisão preventiva.

Nesse particular, consigno que a conduta da ré, a toda evidência, a distancia do melhor interesse das crianças, que, ademais, não pode servir de fundamento para toda substituição da preventiva para prisão domiciliar.

Por fim, não há qualquer informação de ser alguma das crianças portadora de

deficiência.

Por tais motivos, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar formulado, em sede de memoriais escritos, pela Defesa da acusada Gismara.

ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório constante da ação penal proposta pelo Ministério Público contra GISMARA DE LIMA FERREIRA e assim o faço para CONDENÁ-LA como incurso no artigo 33, caput, c.c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, calculada a fração do dia-multa no trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção desde a sua ocorrência, em regime inicial fechado, e sem o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se a acusada no estabelecimento prisional no qual ela já se encontra recolhida, oficiando-se para tanto.

Com o trânsito em julgado:

I - lance-se o nome da ré no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins previstos no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos); e

III - oficie-se ao Setor de Armas e Objetos local para que promova a devida destinação com relação aos objetos apreendidos às fls. 25/26.

A ré está isenta do pagamento de custas processuais, pois se encontra assistida por Defensor nomeado em razão do convênio firmado entre a OAB/SP e a DPE/SP (fls. 105), presumindo-se, assim, o seu estado de miserabilidade e a impossibilidade financeira de arcar com tal despesa. Após a confirmação da interposição ou não de recurso, expeça-se certidão de honorários em favor do Defensor nomeado.

P.I.C.

LEONARDO MARZOLA COLOMBINI
- Juiz de Direito -

Atibaia, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA